

1501316-42.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... acima das disposições relativas ao furto qualificado não impede sua incidência (REsp n. 1.353.693/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2016); b) a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período (EResp n. 842.425/RS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501316-42.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501316-42.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE FABRIAN FRANCO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra Jovane Fabrian Franco de Souza, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal (fls. 103/105). Denúncia recebida em 09 de setembro de 2022, conforme decisão de fl. 107.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita às fls. 158/159.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações do ofendido, inquiridas 2 testemunhas arroladas pelas partes, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve parcial êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, "o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls.47/49), pelo auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls.20/22), pelo auto de avaliação (fls. 18/19), pelo laudo pericial (fls. 112/116) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 03 de Setembro de 2022, por volta das 03h50, no interior do estabelecimento comercial LOJAS CEM, situado à Avenida Luiz Osório nº 747, nesta cidade e comarca, o denunciado JOVANE FABRIAN FRANCO DE SOUZA, agindo durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias moveis, consistentes em 3 três ventiladores marca Mondial - NV61 NP - 6P 40CM, pertencentes à referida empresa.

Segundo o apurado, na madrugada dos fatos, por volta das 3h50, isto é, durante o repouso noturno, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial Lojas Cem para furtar bens do seu interior. O denunciado conduzia o seu veículo Ford/Escort GL, placas BIJ8817, e o utilizou para romper a porta frontal do estabelecimento, que na ocasião estava fechado.

Com este propósito, o denunciado jogou de forma intencional o veículo contra a porta frontal do estabelecimento, arrebentando-a. Na sequência, ingressou no local e do seu interior subtraiu três ventiladores marca Mundial, que estavam expostos à venda (avaliados em R\$ 864,00 - fls. 18/19). O denunciado ainda estourou com as mãos a vitrine dos celulares à venda, mas não os levou, pois o compartimento se encontrava vazio.

Na posse dos três ventiladores, o denunciado ingressou no veículo e deixou o local. A polícia foi acionado e em diligências, prendeu o denunciado em flagrante em sua própria residência. Os três ventiladores estavam no local e foram apreendidos e restituídos à vítima (fls. 21). O veículo usado no crime também estava no local e foi apreendido.

O denunciado confessou o furto (fls. 10).

Houve rompimento de obstáculo (rompimento da porta frontal do estabelecimento pelo veículo) para ingresso no local do crime, conforme exame pericial a ser juntado oportunamente.

O furto ocorreu de madrugada, por volta das 3h50, ou seja, durante o repouso noturno, em período em que a loja estava fechada, o que facilitou a subtração dos bens.

Vejamos.

O acusado Jovane Fabrian Franco de Souza, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "está com dificuldades financeiras, porque não consegue atrair serviços dadas as condições econômicas e a falta de nome no mercado; tem contas de consumo e aluguel em aberto; tem uma filha de 15 dias e está sob os cuidados de sua esposa Patrícia; não tem advogado para indicar, razão pela qual pretende que lhe seja indicado um advogado dativo; disse que ia lá nas Lojas CEM para pegar celulares, mas não tinha, por isso pegou só os três ventiladores; que estava com o carro e colidiu contra a porta, a arrebentando, e seguida, adentrou à loja, se dirigiu ao mostruário de celulares, quebrou a vidraça que o garante; que passou por diversas vezes pelo local dos fatos, mas não com intenção de furtar; pediu pela liberação do veículo que uso para cometer o crime, sendo orientado a requerer judicialmente, a fim de que fosse vendido pela esposa para sustentar a filha; disse que não ofereceu nenhuma resistência e autorizou o ingresso da equipe da Polícia Militar ingressar na sua residência, tendo indicado onde estavam os ventiladores subtraídos; disse que ia vender avulso sem ideia do preço que praticaria; que está arrependido dos fatos; que saiu direto de casa para o local dos fatos" (sic) (fl. 10).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado Jovane Fabrian Franco de Souza confessou a autoria delitiva. Sustentou que praticou o furto que lhe está sendo imputado e está arrependido. Praticou o fato por estar com contas em aberto. Colidiu o veículo que conduzia na porta da loja, que ficou entortada. Já foi processado e condenado. Todos os objetos subtraídos foram entregues aos policiais. A vítima Felipe Henrique Pentiado "representante da empresa", ao ser ouvida na fase policial, narrou que "é gerente da "Lojas CEM", filial de Penápolis; que hoje, por volta das 04 horas, foi acionado pela equipe de monitoramento da matriz, informando que houve acionamento do alarme; diante disso, acionou a Polícia Militar, e durante o contato, foi informado que já havia uma solicitação feita por vizinhos; que se deslocou de sua residência para a loja, visualizando que foram danificadas as quatro portas da frente loja; na hora, conseguiu identificar que foram subtraídos três ventiladores de aproximadamente R\$ 300,00 cada um; ainda não identificaram se houveram outras mercadorias subtraídas; encontrou com os Policiais Militares lá na loja; na própria loja dispõe de sistema de monitoramento e gravação, com acesso apenas pela matriz; disponibilizou para a equipe de plantão o vídeo que contém a dinâmica dos fatos" (sic) (fl. 21).

As testemunhas Evandro Fabiano Martins e Fabricio Polon dos Santos, policiais militares, em solo policial, disseram que "Que assumiu o plantão às 05h30, junto ao Cb Polon, e se deslocou até o local dos fatos, onde havia outra guarnição elaborando o registro da ocorrência, composta pelo Cb Gonçalves e o Cb Luciano, que lhes passaram informações sobre o ocorrido, as características do veículo e do indivíduo; já tinha outra guarnição fazendo patrulhamento pela cidade em busca do indivíduo. composta pelo Cb Thomaz e Cb Amancio; continuaram as diligências da equipe anterior no sentido de encontrar o veículo e o indivíduo e, no bairro Benone Soares, havia uma garagem com sinais abandonada na esquina, localizada na Rua Luiz Beneciuti, nº 979, e a casa ao lado; neste local havia o veículo com as características passadas pela guarnição, porém encoberto parcialmente por uma lona para dificultar a identificação; o portão estava aberto e descobriram a lona; não havia ninguém, até então, nem haviam objetos dentro dele; a dianteira do veículo apontava marcas de colisão, com faróis quebrados e faltando um pedaço do para-choque, tinta do capô se soltando facilmente; na casa ao lado, foram ouvidas vozes, e se deslocaram para frente do portão, e um indivíduo abriu o portão e se deparou com a Testemunha e seu parceiro, Cb Polon, e já se rendeu de imediato, indicando onde estavam as mercadorias subtraídas (ventiladores); o indivíduo permitiu a

vistoria na casa pela Testemunha e pelo parceiro, não tendo nenhum outro ilícito sido encontrado; o capturado foi algemado pelo fundado receio de fuga e pela manutenção da segurança da equipe e o conduziu ao Plantão Policial; que o Capturado está com um machucado na mão, decorrente de ter quebrado uma vidraça de mostruário de celulares, havendo respingo de sangue no chão". "Que assumiu o plantão às 05h30, junto ao Sd Luciano, e se deslocou até o local dos fatos, onde havia outra guarnição elaborando o registro da ocorrência, composta pelo Cb Gonçalves e o Cb Luciano, que lhes passaram informações sobre o ocorrido, as características do veículo e do indivíduo; já tinha outra guarnição fazendo patrulhamento pela cidade em busca do indivíduo. composta pelo Cb Thomaz e Cb Amancio; continuaram as diligências da equipe anterior no sentido de encontrar o veículo e o indivíduo e, no bairro Benone Soares, havia uma garagem com sinais abandonada na esquina, localizada na Rua Luiz Beneciuti, nº 979, e a casa ao lado; neste local havia o veículo com as características passadas pela guarnição, porém encoberto parcialmente por uma lona para dificultar a identificação; o portão estava aberto e descobriram a lona; não havia ninguém, até então, nem haviam objetos dentro dele; a dianteira do veículo apontava marcas de colisão, com faróis quebrados e faltando um pedaço do para-choque, tinta do capô se soltando facilmente; na casa ao lado, foram ouvidas vozes, e se deslocaram para frente do portão, e um indivíduo abriu o portão e se deparou com a Testemunha e seu parceiro, Sd Fabiano, e já se rendeu de imediato, indicando onde estavam as mercadorias subtraídas (ventiladores); o indivíduo permitiu a vistoria na casa pela Testemunha e pelo parceiro, não tendo nenhum outro ilícito sido encontrado; o capturado foi algemado pelo fundado receio de fuga e pela manutenção da segurança da equipe e o conduziu ao Plantão Policial; que o Capturado está com um machucado na mão, decorrente de ter quebrado uma vidraça de mostruário de celulares, havendo respingo de sangue no chão" (sic) (fls.15/17).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Evandro Fabiano Martins e Fabricio Polon dos Santos sustentaram que no dia dos fatos estavam de serviço, tendo sido informados de um furto ocorrido no estabelecimento LOJA CEM. O autor do fato teria batido com o veículo na porta da loja e subtraiu ventiladores, tendo deixado o local dos fatos. Com base nas imagens das câmeras de vigilância, encontraram o automóvel que aparecia nas câmeras em um terreno baldio coberto com uma manta ou coberta. A parte da frente do veículo estava danificada. Ouviram vozes de uma casa ao lado. Na residência foram recebidos pelo réu, que confessou a autoria delitiva, bem como apontou para os ventiladores subtraídos. Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que o ofendido e as testemunhas de acusação tivessem qualquer motivo para pretenderem incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabem inocente. Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Finalmente, e não menos importante, o denunciado foi flagrado na posse da res furtiva, não tendo apresentado versão crível e convincente a respeito da posse de boa-fé.

O Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedentes no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, ou de terceiro que com ele afirma ter praticado o delito, constitui indício de autoria da prática delitiva e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a posse de boa-fé. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal 0005611-17.2015.8.26.0451; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017; Apelação Criminal 0002510-31.2014.8.26.0281; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016; Apelação Criminal 0013310-

97.2014.8.26.0482; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de Registro: 07/04/2016.

5. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta é materialmente atípica.

O pleito defensivo deve ser indeferido.

O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade, mediante uma interpretação restritiva do tipo penal.

Seu reconhecimento depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. São requisitos objetivos: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social do agente; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica.

Os requisitos subjetivos (dizem respeito às condições do agente e da vítima), por seu turno, são dois: (i) importância do objeto material para a vítima (devendo ser avaliado o valor sentimental do res furtiva, bem como a situação econômica do agente e do ofendido); e b) circunstâncias e resultado do crime.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “no crime de furto, avalia-se notadamente: a) o valor do bem ou dos bens furtados; b) a situação econômica da vítima; c) as circunstâncias em que o crime foi perpetrado, é dizer, se foi de dia ou durante o repouso noturno, se teve o concurso de terceira pessoa, sobretudo adolescente, se rompeu obstáculo de considerável valor para a subtração da coisa, se abusou da confiança da vítima, etc.; d) a personalidade e as condições pessoais do agente, notadamente se demonstra fazer da subtração de coisas alheias um meio ou estilo de vida, com sucessivas ocorrências (reincidente ou não)” (STJ – HC 208.569/RJ, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, julgado em 22/04/2014 – grifo meu).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado mediante escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em razão da maior reprovabilidade do comportamento e da efetiva periculosidade social do agente. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1627582/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020; AgRg no HC 550.972/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

Ademais, o acusado é reincidente (processo n.º 1500907-47.2020.8.26.0438) e portador de Maus antecedentes (processos n.º 0005521-16.2016.8.26.0502; 0007580-92.2016.8.26.0496; 0007640-47.2016.8.26.0502), circunstância(s) que obsta(m) a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1005824/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; AgRg no HC 387.224/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017.

Finalmente, no caso de furto perpetrado durante o repouso noturno, a jurisprudência pátria vem decidindo que não se aplica o princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade do comportamento do agente. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 373.139/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016. Desse modo, rejeito o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

6. Impõe-se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

De acordo com a doutrina, “Destruição é o comportamento que faz desaparecer alguma coisa. Destruir é subverter ou desfazer totalmente algo. Exemplo: explosão de um cofre. Rompimento, por sua vez, é a atividade consistente em deteriorar algum objeto, abrir brecha, arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, forçar de qualquer modo um objeto para superar sua resistência e possibilitar ou facilitar a

prática do furto. Exemplo: abrir o cofre com uma barra de ferro, forçando sua porta. Obstáculo é a barreira, o empecilho que protege um bem, dificultando sua subtração. Pode ser externo (exemplo: cadeado) ou interno (exemplo: grade de proteção), e ativo (exemplos: cerca elétrica e armadilhas) ou passivo (exemplos: portas, fechaduras e janelas)” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212). Vol. 2. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 397 – grifo meu).

Cabe destacar que a qualificadora em análise somente pode ser aplicada quando a destruição ou rompimento do obstáculo ocorrer antes ou durante a consumação do furto, ou seja, quando servir como meio de execução para a subtração da coisa alheia móvel.

Finalmente, “Como a destruição e o rompimento de obstáculo deixam vestígios, é imprescindível a elaboração de exame de corpo de delito, direto ou indireto, para comprovação da materialidade, não podendo a confissão do acusado substituí-lo (CPP, art. 158). Mas, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (CPP, art. 167)” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212). Vol. 2. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 398 – grifo meu).

No caso dos autos, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi atestada não apenas pelas declarações do ofendido e pelos depoimentos das testemunhas, mas também pela confissão do acusado e pelo laudo pericial de fls. 112/116.

7. Impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno, porquanto a referida causa de aumento somente se aplica ao furto simples.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vinha reiteradamente decidindo que a causa de aumento do § 1º, do artigo 155, do CP, seria aplicável tanto à forma simples (caput) quanto à forma qualificada (§ 4º) do delito de furto, com base nos seguintes fundamentos: a) a circunstância de a causa de aumento encontrar-se topologicamente acima das disposições relativas ao furto qualificado não impede sua incidência (REsp n. 1.353.693/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2016); b) a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período (EResp n. 842.425/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe de 2/9/2011); c) a circunstância em que se dá a causa de aumento de pena pelo cometimento de furto durante o repouso noturno guarda compatibilidade com o tipo penal furto, simples ou qualificado, não se constatando, nesse proceder, assimetria (objetiva ou subjetiva) quando da conjugação desses dispositivos na aplicação da pena (AgRg no HC n. 674.534/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021; AgRg no HC n. 697.683/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/11/2021; AgRg no REsp n. 1.821.939/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/6/2020; REsp n. 1.353.693/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2016; AgInt no HC n. 439.716/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 01/08/2018). Todavia, no julgamento de recursos especiais representativos da controvérsia, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania decidiu rever o referido entendimento para fixar o seguinte precedente judicial (Tema n.º 1.087): “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (REsp n.º 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022 – grifo meu).

Ressalte-se que, nos termos do artigo 927, caput, do CPC (que se aplica subsidiariamente ao processo penal, nos termos do artigo 3º do CPP), “Os juízes e tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (grifo meu).

Conforme entende a doutrina e a jurisprudência pátrias, “o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos em seus incisos. Ou seja, 'observarão' significa aplicação de forma obrigatória, já havendo precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido

de admitir a eficácia vinculante dos precedentes previstos no inciso V do art. 927 do Novo CPC (Informativo 600/STJ, 3ª Turma, REsp 1.655.722/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2017, DJe 22/03/2017)" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado: artigo por artigo. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1550 - grifo meu).

II.3. Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no REsp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui Maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0005521-16.2016.8.26.0502; 0007580-92.2016.8.26.0496; 0007640-47.2016.8.26.0502.

Considerando-se que o acusado ostenta 3 condenações definitivas que não configuram reincidência, aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; REsp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no REsp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Compenso a agravante da reincidência (processo n.º 1500907-47.2020.8.26.0438) com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime aberto, os péssimos antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto, a despeito da quantidade de pena aplicada, os péssimos antecedentes e a reincidência indica(m) que, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para

condenar o(a) acusado(a) JOVANE FABRIAN FRANCO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA